

1500483-04.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... sobre seu possível envolvimento pretérito com o narcotráfico.

Neste ponto, a forma que as drogas foram localizadas pelos agentes da lei, como se vê de seus depoimentos acima, indicam, também, que apesar de ter aceitado essa vil tarefa do tráfico, em coautoria com o seu tio, Marcelo somente as guardava, vez que não estavam espalhadas pelo seu imóvel, mas, tudo se encontrava dentro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500483-04.2021.8.26.0621 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500483-04.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2132445/2021 - Delegacia de Polícia de Canas, 17932719 - Delegacia de Polícia de Canas, 424/21/204 - Delegacia de Polícia de Canas, 2132445 - DEL.POL.CANAS, 424/21/204 - DEL.POL.CANAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO AUGUSTO ROCHA e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de MARCELO AUGUSTO ROCHA e FELIPE RENATO ROCHA, qualificados nos autos, na qual lhes é atribuída a prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 29, "caput", do Código Penal, pelos fatos narrados na peça inicial de fls. 124/125.

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados e apresentaram as suas defesas prévias (Marcelo, às fls. 153/156, e Felipe, à fl. 159). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento, nos termos dos artigos 56 e seguintes, da Lei 11.343/06 (fls. 163/165).

No curso da instrução foram ouvidas as testemunhas e os informantes judiciais,

sendo os réus, ao final, interrogados. Na sequência, as partes apresentaram alegações finais em audiência (mídia à fl. 247).

O Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal, com a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa de Marcelo requereu a improcedência da ação penal, por carência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Sustentou que a quantidade e diversidade dos entorpecentes não podem ser consideradas na primeira e terceira fase, sob pena de bis in idem. Por fim, pugnou pelo estabelecimento do regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Já a defesa de Felipe requereu: o reconhecimento da confissão espontânea; a aplicação da pena no mínimo legal; a aplicação da redutora prevista no parágrafo quarto do tipo penal em questão (tráfico privilegiado); o estabelecimento do regime inicial menos severo e; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É O RELATÓRIO.  
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), fotografias (fls. 45/52), laudo de constatação provisória (fls. 59/62) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 140/142 e 240/242), cujos resultados foram positivos para “cocaína e tetrahydrocannabinol - THC - maconha”, substâncias presentes nas listas, da Portaria SVS/MS 344/98, e atualizações posteriores; bem como as provas orais existentes nos autos.

A prova de autoria também é inconteste, comprometendo sobremaneira a dupla de acusados. A começar pelo próprio estado flagrancial e a confissão espontânea de Felipe. Senão vejamos.

O policial militar André Luiz de Jesus da Silva, declarou que na data dos fatos recebeu uma informação dando conta de que havia drogas na casa do corréu Marcelo. Diante disso para lá rumou, local onde foram atendidos pelo próprio, que o indicou onde os narcóticos estavam. De acordo com o depoente, Marcelo lhe contou que tais entorpecentes pertenciam ao seu tio, ora corréu Felipe, o qual lhe pedira para que os guardasse em sua residência. Assim, após a apreensão das drogas, seguiu até a casa de Felipe. Lá, este confirmou a versão do sobrinho, dizendo que, realmente, havia deixado os narcóticos na casa daquele. Questionada, a testemunha negou que já conhecesse os réus. Disse que a mochila contendo as drogas encontrava-se em local de fácil visualização, dentro do imóvel de Marcelo, mais precisamente, na sua garagem. De acordo com o declarante, a delação anônima que ensejou a ação policial dizia que Marcelo não se encontrava em casa naquele momento, somente as drogas. Assim, a testemunha dirigiu-se até a casa de sua mãe, onde o acusado foi encontrado e, após ser cientificado da denúncia, este os acompanhou até a sua casa, objeto da denúncia.

Seu companheiro de farda, Ricardo Pouza de Carvalho, fez eco às suas declarações.

Já o irmão de Marcelo e informante judicial, Gean Augusto de Araújo, contou que o acusado trabalhava consigo na mesma empresa há quatro anos, sendo um excelente profissional, na área de cortador de vidros. Negou que soubesse o envolvimento do irmão com o vil comércio, afirmando que este sempre foi uma pessoa tranquila, não

bebia, não fumava, frequentava a igreja, e as reuniões de família.

Por sua vez, a esposa de Marcelo, outra informante judicial ouvida (Júlia Medeiros Maseli Pinto), disse que o marido é pessoa de boa índole, trabalhador, mantenedor da casa, além de terem juntos, um filho. Declarou que na data dos fatos, Marcelo chegou do trabalho e foi lhe buscar em casa para que fossem jantar na casa de sua sogra. Disse que no momento do jantar, os policiais chegaram e informaram que haviam recebido uma denúncia anônima acerca de uma briga de casal em sua casa, e que o imóvel encontrava-se aberto. Tal informante contou, ainda, que os agentes da lei pediram para Marcelo lhes acompanhar para verificar sua residência.

Em seu interrogatório, Marcelo negou os fatos. Contou que estava jantando na casa de sua mãe, quando os policiais militares chegaram e informaram que haviam recebido informações de que em sua casa ocorria uma briga conjugal, e que o imóvel encontrava-se aberto, com o portão estourado. Disse que chamou sua esposa Júlia para o acompanhar, porém, os policiais disseram que não seria necessária a presença daquela, pois iriam até o local somente para fechar o imóvel. Entretanto, ao chegar a sua casa, encontrou o imóvel todo revirado, com policiais saindo do seu interior. Passado alguns instantes, viu alguns policiais mexendo no quintal e dizendo que nada haviam encontrado ali. Na sequência, os policiais lhe pediram para assinar um papel, autorizando a entrada deles no imóvel novamente. Ato contínuo, o interrogando disse ter visto dois policiais passando, por detrás da cerca de sua casa, um deles segurando uma mochila. Imediatamente, os policiais colocaram as drogas na viatura e pediram para que entrasse no imóvel, passando a agredi-lo para que apontasse o dono delas, informação que desconhecia. De acordo com o acusado, os policiais lhe disseram para apontar Felipe, como proprietário dos entorpecentes. Em seguida, os agentes públicos o levaram até a casa de seu tio, sendo que, ao chegar lá, viu que o corréu já se encontrava no interior da viatura. Negou que seja envolvido com drogas, ou mesmo que conhecesse os policiais envolvidos na ocorrência. Afirmou, também, que não foi submetido ao exame de corpo de delito, vez que os agentes da lei o obrigaram a dizer que não havia sido agredido, acrescentando que, embora não conste de seu depoimento, chegou a dizer a esse respeito no distrito policial. Por fim, afirmou que trabalhava em uma empresa há quatro anos, sustentando sua casa com o salário que recebia.

Por outro lado, o outro acusado, Felipe Renato Rocha, confessou parcialmente os termos da denúncia. Admitiu que, realmente, pegou a droga apreendida para guardar, pois devia uma alta quantia à traficantes, dívida esta que não possuía condições de honrar. Contou que, por medo do que poderia acontecer, concordou em pegar os entorpecentes numa quinta-feira (dia 13 daquele mês) para guardar consigo. Porém, como soube que vizinhos o haviam denunciado à polícia, em razão de som alto na sua residência, pegou a mochila com os entorpecentes, e a escondeu em um campo abandonado situado no final da sua rua, o qual não faz parte da residência de Marcelo. Contou que pretendia buscar a mochila na madrugada de sexta-feira para entregá-la ao seu dono e assim, quitar sua dívida. Indagado, disse que na data e horários dos fatos estava em sua casa, na companhia de sua mãe, quando os policiais lá chegaram e lhe disseram que estava preso, juntamente com Marcelo, seu sobrinho. Disse que mora na Rua Parati, enquanto Marcelo reside na Rua Osvaldo Ortiz Monteiro. Ao cabo de sua autodefesa, esclareceu que não conhecia os policiais que o prenderam.

Essas são as provas dos autos.

Pois bem. Como se vê, a negativa de Marcelo mostra-se absolutamente refratária às demais provas dos autos, não convencendo este Juízo.

De outro lado, quanto à confissão de Felipe, à luz do interesse público em jogo, vez que este tenta, em vão, afastar a participação de seu sobrinho na empreitada criminosa, passo a analisar a postura daquele acusado frente as demais provas,

verificando se há convergência ou divergência no cotejar de todas elas.

No caso dos autos, a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida pelo increpado, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro para a condenação dele próprio, vez que os demais elementos de convicção, presentes nos autos, corroboraram com a sua responsabilidade pelas drogas, ainda que apreendidas em outro local.

Neste ponto, importante registrar, ainda que não alegado expressamente pela defesa, dificuldades financeiras para quitar dívida pretérita oriunda do consumo de estupefacientes, não configura a excludente de ilicitude, do artigo 23, do Código Penal.

Isto porque, Felipe não trouxe qualquer elemento que permitisse aferir que tivesse fato agido por estado de necessidade, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal.

De outra parte, forte no artigo 24, do Código Penal, não se insere no conceito de estado de necessidade a prática de tráfico de entorpecentes para adimplir dívidas com traficantes, como asseverado por esse increpado, em sua autodefesa, visto que somente deve ser reconhecida aquela excludente diante da sua involuntariedade e estado atual, o que não ocorre neste caso, dado que tal pendência financeira fora contraída por livre e espontânea vontade, sem contar a existência de outras formas de quitá-la com o passar do tempo.

Neste sentido, o mesmo entendimento do nosso Tribunal:

"Tráfico - Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 - Robusto conjunto probatório - Autoria e materialidade devidamente comprovadas, as quais sequer foram questionadas pelo recurso - Pleito para reconhecer as excludentes pelo estado de necessidade e pela inexigibilidade de conduta diversa - Embora a defesa tenha sustentado que o réu adquiriu as drogas para pagar dívidas de traficantes, tal fato não foi efetivamente demonstrado nos autos e, mesmo se fosse, os requisitos das excludentes não foram cumpridos (...). Além disso, quem deu causa ao caso hipotético foi ele mesmo, pois não quitou a dívida - A alegação de inexigibilidade de conduta adversa não prospera, uma vez que ela é aplicável em casos extremos, nos quais ao agente não é exigível a conduta conforme o direito. Não é crível que a prática do tráfico ilícito de drogas fosse o único comportamento diante das supostas circunstâncias, sendo inaceitável a alegação do réu de que não dispunha qualquer outro meio para lidar com a suposta ameaça dos traficantes - Pena e regime inalterados - Recurso defensivo improvido". (TJSP; Apelação Criminal 1500964-60.2018.8.26.0042; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Altinópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020) (Sublinhado na reprodução).

Lado outro, não há como encampar a alegação sustentada em Juízo por Felipe de que Marcelo desconhecia a existência dos narcóticos, diante de frontal divergência com as demais provas dos autos.

Veja-se que a única tese defensiva dos acusados é lançar dúvidas às declarações apresentadas pelas testemunhas arroladas pela acusação, as quais foram categóricas ao afirmar que os réus confessaram informalmente a responsabilidade pelas drogas apreendidas, na casa de Marcelo, alvo de informações anônimas anteriores.

Neste ponto, malgrado este Juízo já tenha sustentado em decisões anteriores, nunca é demais reforçar a credibilidade que costume conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, guardas municipais, ou mesmo, qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020);

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que um policial; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso da militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, ele próprio, violá-la, com o fito de incriminar um inocente? Não faz qualquer sentido!

Frise-se que os agentes estatais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, não conheciam os réus, que sequer ostentam outras passagens policiais, ou seja, são completamente desconhecidos dos meios policiais.

E não é só. Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem, em desfavor dos acusados, sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, como no caso, afinidade ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõe a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de uma pessoa se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que presenciou, por exemplo. Qual pai de família, em sã consciência, se apresentaria à autoridade policial e/ou ao juiz, para entregar um traficante? Ainda mais sabendo que continuará a residir no

local dos fatos.

Diante disso, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. O mesmo vale para confissão do réu. Não nos encontramos mais nos primórdios do processo penal. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas. Todas são relativas!

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput" do CPP, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisor o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Destarte, observo que o caso, ora em apreço, é semelhante a tantos outros vistos no cotidiano forense envolvendo o narcotráfico, no qual um dos réus, vendo sua iminente condenação, chama para si toda responsabilidade pelos fatos, ao mesmo tempo em que tenta livrar o sobrinho.

Todavia, a narrativa de Felipe no sentido de que, após ser informado por um vizinho da possível chegada de policiais em sua residência, resolveu esconder a droga em outro lugar e, por infelicidade, acabou colocando-a próximo à casa de corréu Marcelo, não faz qualquer sentido. Afinal, por qual razão Felipe não escondeu a droga no período noturno, em local longe da casa de seu sobrinho, e mais próxima de sua própria casa, como bem apontado pela representante do Ministério Público.

Observe-se que Felipe reside na última via pública daquele local, sendo que os arredores são lugares de vegetação, estrada vicinal em direção à rodovia Presidente Dutra, sem outras residências, sendo que os imóveis mais próximos são os fundos de lojas de materiais de construção e cerâmicas. Assim, por que Felipe andaria, à noite, até local fronteiro à casa de Marcelo para esconder as drogas?

Veja-se que, ainda que acreditássemos nessa versão, como os policiais receberam informações indicando que as drogas estavam na casa de Marcelo? E outra: depois de encontrá-las, como saberiam que eram de Felipe, se Marcelo nada sabia sobre tais entorpecentes?

E tem mais. Felipe permaneceu em silêncio em sede policial, vindo somente em juízo,

passados aproximadamente oito meses da prisão de seu sobrinho, confessar a sua autoria, e isentá-lo. Por qual motivo assim não o fez em sede policial, ocasião em que estava acompanhado por defensora constituída?

Por sua vez, por que Marcelo, ainda no "calor" dos fatos, não negou a posse da grande quantidade e diversidade de entorpecentes, denunciando a alegada conduta ilegal e irresponsável dos policiais militares, que encontraram as drogas fora de sua residência e, ainda, o agrediram?

Ora, se por um lado, tal postura revela o exercício de um direito assegurado constitucionalmente aos acusados, de outro, nesse caso específico, causa estranheza os réus não terem levado ao conhecimento da autoridade policial, integrante da polícia civil, como se sabe, distinta daquela que realizou a prisão, todas essas ilegalidades dos policiais militares; principalmente, porque acompanhados de advogada constituída.

Neste ponto, não há como acreditar que o perito criminal, a autoridade policial e a advogada, repiso: contratada pelos próprios acusados, encampariam suposta versão fantasiosa dos policiais militares, ocultando, inclusive, no caso do "expert", os sinais das agressões sofridas por Marcelo, já que não constaram do laudo pericial de fls. 57/58.

Insta salientar, ainda, que tais agressões sequer fazem sentido nessa versão defensiva, vez que, segundo esse réu, os policiais lhe forjaram as drogas e já sabiam, ou almejavam, implicar o seu tio Felipe. Logo, bastava conduzi-los ao distrito policial, não sendo necessário fazê-lo confessar ou apontar o proprietário dos entorpecentes engendrados por aqueles agentes públicos.

Assim, acolher narrativa que agentes da lei, em conluio com médico perito e advogada; agrediriam, gratuitamente esse acusado, que sequer conheciam, seria não só fechar os olhos a uma realidade manifesta nos autos e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego as normas da verdade e do bom senso, como também desprestigiar as palavras dos próprios policiais, agentes que gozam de ampla credibilidade junto ao Poder Judiciário, sobretudo, por não terem qualquer interesse em incriminar inocentes.

Registro, também, que os informantes judiciais nada trouxeram aos autos que retirasse a credibilidade da palavra dos policiais militares, vez que a esposa de Marcelo não acompanhou o desenrolar dos fatos, nem o irmão dele.

Portanto, os réus não apresentaram nenhuma prova admitida em direito que afastasse a credibilidade das declarações daquelas testemunhas acusatórias, bem como não se desincumbiram do seus ônus de provar estratégia criada para incriminá-los, nem mesmo apontaram motivo sério que permitisse tal conclusão, diante da ausência de qualquer lastro probatório nesse sentido, a teor do disposto no artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS – PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 0001394-

33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Por fim, sobre as condutas tipificadas no artigo 33, da Lei 11.343/06, esclareço que é desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso, como nos presentes autos, diante das quantidades e diversidade de entorpecentes e da forma que embalados, indicando sem sombra de dúvidas o fim mercantil daqueles narcóticos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares - Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Tipo penal que prevê diversas condutas - Desnecessidade da prova da efetiva mercancia - Condenação mantida - (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Portanto, o caso é de condenação, nos exatos termos da denúncia, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, especialmente, o expressivo volume e diversidade dos narcóticos, indicam claramente que estes tinham como destino o consumo de terceiros.

Passo às penas.

a) MARCELO AUGUSTO ROCHA:

Nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, o juiz na aplicação da pena deve considerar, com preponderância das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a natureza, quantidade, personalidade e conduta social.

O réu é primário e sem antecedentes criminais. Além disso, observo inexistirem informações nos autos que desabonem sua conduta social. Muito pelo contrário, posto que as informações prestadas por esposa e seu irmão, dão conta de que Marcelo é pessoa de bem e trabalhador. Porém, certo é que a quantidade, diversidade e natureza dos narcóticos apreendidos (236 gramas, de "skunk"; 1.176 gramas, de cocaína, prontos para venda, vez que distribuídos em 944 pinos plástico, do tipo "eppendorf"; 2.036 gramas, de cocaína, no formato de dois "tijolos"; 32 gramas, de "crack"; e 664 gramas, de "maconha", divididas em 263 porções), apontam para maior risco ao bem jurídico tutelado por este tipo penal (saúde pública), não podendo este julgador, aplicar a mesma sanção devida à culpabilidade normal à espécie.

Ademais, como se vê, o presente caso envolve grande quantidade de "cocaína", além do maldito "crack", droga de enorme capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia, sendo que pode viciar até no primeiro uso, denotando-se reprovabilidade maior à conduta censurada, devido à natureza desse entorpecente.

No mesmo sentido, em julgado recente:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) - Sentença absolutória - Recurso ministerial almejando a condenação - Necessidade - Materialidade que decorre de prova documental - Autoria suficientemente demonstrada pela prova oral - (...) - Pena-base exasperada em função da natureza (crack e cocaína) de parcela das drogas - Inteligência do art.



42 da Lei nº 11.343/06 - (...) - Conduta concretamente grave, envolvendo tráfico de significativa quantidade e variedade de drogas, dentre as quais crack e cocaína, de poder vulnerante acentuado - Substituição da pena corpórea por restritivas de direitos defesa - Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1517986-53.2021.8.26.0228; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2021; Data de Registro: 10/12/2021) (Sublinhados meus).

Logo, diante dessas circunstâncias extremamente desfavoráveis, tenho por bem fixar a pena-base em 2/5 (dois quintos) acima do piso legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, não há agravantes ou atenuantes.

Na última fase, em que pese a grande quantidade, diversidade e natureza dos narcóticos apreendidos na casa do acusado, circunstância do caso concreto que poderia revelar a profunda intimidade dele com o narcotráfico, apesar de sua condição de primário aos olhos da lei penal, excepcionalmente, diante de outros elementos dos autos, entendo ser possível o reconhecimento do § 4º, da Lei 11.343/06.

Veja-se que, em consonância com as declarações de sua esposa e de seu irmão, Marcelo trouxe aos autos prova documental de ocupação lícita (fls. 77/81).

Além disso, importa dizer que os policiais militares disseram que não o conheciam até então, nada sabendo, portanto, sobre seu possível envolvimento pretérito com o narcotráfico.

Neste ponto, a forma que as drogas foram localizadas pelos agentes da lei, como se vê de seus depoimentos acima, indicam, também, que apesar de ter aceitado essa vil tarefa do tráfico, em coautoria com o seu tio, Marcelo somente as guardava, vez que não estavam espalhadas pelo seu imóvel, mas, tudo se encontrava dentro de uma mochila.

Assim, diante das especificidades deste caso concreto, reconheço o benefício do § 4º, do artigo 33, da Lei de drogas, em seu grau máximo (dois terços), diante das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, favoráveis ao increpado.

Portanto e, à míngua de outras causas modificadoras, fixo definitivamente as penas em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

b) FELIPE RENATO ROCHA:

Assim como o corréu acima, Felipe não possui maus antecedentes, conforme a certidão criminal de fls. 228/229.

Porém, as nefastas circunstâncias acima expostas são as mesmas para esse acusado, logo, para evitar a tautologia, adoto-as como razão para elevar a pena-base, mantendo a proporcionalidade e razoabilidade, na mesma fração de 2/5 (dois quintos) do piso legal, ou seja, em 07 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o réu confessou a traficância, embora tenha tentado afastar a autoria do corréu.

Nesse sentido:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão parcial de RONALDO, admitindo a traficância e isentando as corrés de responsabilidade.

Negativas das acusadas isoladas do conjunto probatório. (...) Condenações mantidas. Apelo ministerial buscando o afastamento, na terceira fase, do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 para as rés, e a fixação do regime fechado. Admissibilidade. 1) Réu RONALDO: básicas estipuladas em um terço acima dos pisos legais, diante da razoável quantidade e variedade de drogas, além dos maus antecedentes, o que está justificado e fica mantido. Na fase seguinte, de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão, eis que o réu admitiu participação no tráfico de drogas, embora tenha isentado as corrés. Penas que são reduzidas na fração de um sexto, tornando-se definitivas nesses patamares. (...). 4) Apelo de RONALDO parcialmente provido, recursos de FERNANDA e GIOVANNA improvidos e irresignação ministerial acolhida". (TJSP; Apelação Criminal 1511195-39.2019.8.26.0228; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021) (Original sem marcação).

Em consonância com a jurisprudência sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". (SÚMULA 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

Logo, atenuo as penas em 1/6 (um sexto), ao patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornada definitiva, por inexistirem outras circunstâncias alteradoras.

Esclareço que, ao contrário de seu sobrinho, Felipe não faz jus ao tráfico privilegiado, na medida em que as circunstâncias do caso concreto revelam sua profunda intimidade com o narcotráfico, apesar de sua condição de primário aos olhos da lei penal.

Ademais, Felipe sequer comprovou ocupação lícita, como fez Marcelo, restando comprovada sua dedicação às atividades espúrias, requisito a afastar a incidência dessa benesse legal.

Neste ponto, cabe salientar não serem apenas a quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes que conduzem para essa conclusão, haja vista a própria confissão de Felipe, assumindo a propriedade das drogas que o seu sobrinho guardava e a relação com traficantes maiores, que lhe incumbiram dessa vil empreitada, indicando, não se tratar de traficância eventual.

Mesmo entendimento do Tribunal de Justiça, em recentes julgados:

"APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - (...) - Dosimetria - Aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas - Impossibilidade - quantidade de drogas (MAIS DE 1 TONELADA) e circunstâncias que indicam a dedicação do acusado à atividade criminosa - Regime inicial fechado - Necessidade - Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido". (TJSP; Apelação Criminal 1501017-24.2021.8.26.0628; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/01/2022; Data de Registro: 14/01/2022); e

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - (...) Condenação mantida - Dosimetria - Aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em patamar máximo - Desacolhimento - Circunstâncias do crime, especialmente a quantidade e natureza das drogas apreendidas e informações de que o acusado era o responsável pela distribuição de drogas no bairro, que indicam que ele dedicava-se a atividade criminosa, fazendo o tráfico seu meio de vida - Precedentes do STJ e do STF - (...) - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1501537-30.2021.8.26.0548; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito

Criminal; Foro de Campinas - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2021; Data de Registro: 18/12/2021) (Ênfase minha).

Aliás, como não existe prova direta dessa circunstância, dedicar-se à atividade criminosa, como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'", é exatamente essas circunstâncias que comprovam a sua dedicação, conforme julgado que assim se encontra a ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada". (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

Assim, como determina a lei, tal redutora não se destina àquele que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, hipótese de Felipe, mas sim, ao agente que age por um impulso esporádico, em caso isolado, incidindo, portanto, em situações específicas e excepcionais, quando evidenciado que o pequeno tráfico se tratou de singelo desvio na vida do acusado.

Lado outro, nem se argumente que, ao afastar a benesse legal, ora em voga,

estariamos diante de uma hipótese de bis in idem, posto que a expressiva quantidade, diversidade e natureza da droga não foi isoladamente considerada por este Julgador para tal fim.

Confira-se no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça deste estado:

“Agravamento regimental em embargos de declaração em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de drogas: 3,410 quilos de maconha) à pena de 5 anos de reclusão, regime inicial fechado com base na hediondez já afastada por ocasião da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração. 4. Irresignação persistente quanto a não aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de bis in idem na dosimetria da pena que se afasta. 5. Jurisprudência desta Suprema Corte quanto a possibilidade de se utilizar a quantidade de droga para fixar a pena-base acima do mínimo legal e a conclusão, com base no contexto dos fatos, de que o paciente se dedica a atividades criminosas, dada a quantidade de droga apreendida. (...) 8. Agravamento regimental a que se nega provimento.” (STF; HC 154462 ED-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/11/2018, processo eletrônico dje-262 divulg 05-12-2018 public 06-12-2018);

“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. (...). 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elege-se dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. (...) 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença”. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021); e

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO –

Insurgência defensiva que recai somente sobre o primeiro delito - (...) - Dosimetria - Redução da pena-base - Impossibilidade - Quantidade e natureza do entorpecente apreendido que autoriza a elevação da sanção inicial - Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, que deve preponderar sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal - Aplicação da causa de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em patamar máximo - Desacolhimento - Considerável quantidade de entorpecente apreendido em poder do acusado ('maconha', 'crack' e 'cocaína') que evidencia sua dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência da benesse legal - Possibilidade de consideração da quantidade e variedade de entorpecente a justificar a dedicação do acusado à atividade ilícita com habitualidade - Inocorrência de 'bis in idem' no sopesamento dessas circunstâncias para elevar a pena-base e para afastar o aludido redutor - Precedentes do STJ e do STF - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500280-28.2021.8.26.0270; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/12/2021; Data de Registro: 18/12/2021) (Sublinhados meu).

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, anote-se que o delito de tráfico é equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a atual redação do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e, por isso, não se mostra razoável a incidência do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em que pese não seja obrigatório o regime mais gravoso, devido ao C. Supremo Tribunal Federal - STF ter reconhecido, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo citado (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli).

Porém, convém lembrar, na esteira do julgado citado da Suprema Corte, que isso não invalida a discricionariedade judicial, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado.

Fixada tal diretriz, no que se refere ao corrêu Felipe, fixo o regime inicial fechado para o início do desconto da pena corporal que lhe foi aplicada, em vista das circunstâncias concretas acima expostas, reforçando-se, como exemplo, a quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Quanto ao regime inicial de Marcelo, insta salientar que, malgrado este Julgador possua posicionamento pessoal em sentido contrário, por entender ser vedado ao legislador ordinário reduzir o conceito de tráfico de drogas, ante o caráter hediondo que lhe foi destinado pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII, em razão da eficácia paralisante, decorrente das chamadas normas constitucionais de eficácia limitada, da qual é exemplo aquela supracitada, certo é que o Pretório Excelso sedimentou o entendimento que o tráfico, na sua forma privilegiada, não se reveste de hediondez.

Nesse sentido:

"(...) a Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade como previsto no art. 33 do

Código Penal (HC nº 118.776/MG, da relatoria do Ministro Nilson Naves, julgado em 18.3.2010), bem como a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos." (STJ, HC nº 189.931/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.5.2012);

"Ocorre que, em recentes julgados, esta Segunda Turma concedeu a ordem a pacientes condenados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com afastamento da regra do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determina o cumprimento no regime inicial fechado, para permitir lhes que iniciem o cumprimento das suas reprimendas no regime aberto, porque presentes, no caso concreto, os requisitos previstos no art. 33, II, c, do Código Penal." (STF, HC 109.343/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, V.U., j. 03.4.2012).

Assim, em prestígio à uniformidade das decisões judiciais, corolário do princípio da segurança jurídica e, principalmente, ao princípio da isonomia, curvo-me a tal entendimento acerca da figura do "tráfico-privilegiado", ou seja, de que não ostenta natureza hedionda.

Fixada tal diretriz, entendo que seria o caso de fixar o regime inicial semiaberto, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima apontadas. No entanto, considerando que o tempo de prisão preventiva do acusado atingiu o lapso temporal de que trata o artigo 387, § 2º, do Código Processo Penal, estabeleço o regime inicial aberto.

Com relação à substituição da pena privativa de liberdade ou mesmo a aplicação do sursis, cerro fileiras com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no incidente de arguição de inconstitucionalidade, no "habeas corpus" nº 120.353 - SP, pois, a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição descrita no artigo 44, da Lei 11.343/06.

No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos expostos na ementa do referido remédio constitucional, abaixo transcrita, vez que em linha com o princípio da individualização da pena e com a vontade do legislador constitucional:

"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCONVERSIBILIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 33, § 4º E ART. 44, CAPUT, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. Se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juiz o arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituir a pena privativa da liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio art. 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base da violência ou de grave ameaça à pessoa - e com maior razão. Com efeito, as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no art. 44 do Código Penal, tem como suporte unicamente o critério do legislador ordinário; já a inconversibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes têm por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou